

CAPÍTULO 9

LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO

Jorgelina E. Mendicó*

1. Introducción

Como se adelantó en el capítulo 4, los principios generales de derecho —mencionados en el artículo 38 del ECIJ— son postulados, máximas rectoras del derecho en general, que se encuentran en los ordenamientos jurídicos internos, es decir, en el sistema jurídico de todos los Estados, y que también son fuente del derecho internacional.

El derecho internacional público desde sus inicios ha recurrido a la aplicación de principios generales de derecho cuando no se hallaban las reglas aplicables al asunto en otras fuentes tales como los tratados y la costumbre. La jurisprudencia vislumbra la aplicación de principios provenientes del derecho privado a las relaciones de los Estados. En sus inicios, las diferencias en el derecho internacional muchas veces se solucionaban recurriendo a los principios que surgían de las normas provenientes de los sistemas jurídicos internos de los miembros de la comunidad internacional. Con la evolución del derecho internacional, que llevó a la adopción de nuevas normas especiales, la aplicación de esta fuente ha ido menguando.

El Estatuto de la CIJ, en su artículo 38(1), al mencionar las fuentes principales o creadoras del derecho internacional, considera a "los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas" dentro de esa categoría de fuentes. La calificación referida a las "naciones civilizadas"—con la que se pretendía excluir a los sistemas de derecho de las comunidades "primitivas"—indica que *prima facie* solo serán tenidos en cuenta aquellos principios desarrollados por algunos Estados, dejando de lado los que pudieran existir en las naciones que no se consideran civilizadas. Esta categorización de la fuente en la actualidad puede resultar más que controvertida si se tiene en cuenta la posición de aquellos Estados que, cuando las normas se fueron gestando, dependían de una potencia ocupante para luego nacer como nuevos sujetos a raíz del proceso de descolonización.

Los principios generales de derecho —que, como ya se mencionó, son fuente tanto en los ordenamientos internos como en el ordenamiento internacional— no deben ser confundidos con los denominados "principios generales del derecho internacional", a los que nos referiremos más abajo.

2. Los principios generales de derecho en el Estatuto de la CIJ

El Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional —predecesora de la actual CIJ— en su artículo 38(3) expresaba que aquel tribunal debía aplicar los principios generales

* Este pequeño aporte a la obra es dedicado especialmente a Ariel González, quien despertó mi interés en el derecho internacional cuando fui su alumna.

1 Cheng, Bin, *General Principles of Law as Applies by International Courts and Tribunals*, Grotius, Cambridge, 1987, p. 25.

de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. De acuerdo con la doctrina, dicha disposición produjo una crisis en la teoría de las fuentes del derecho internacional. Al parecer, si bien la práctica generalizada era la de aplicar los principios generales de derecho además de los tratados y la costumbre, dicha circunstancia no había llamado la atención de la doctrina durante el siglo XX y principios del XX.

Sobre el particular, Barberis destaca que los estudios y las discusiones se centraban en determinar si la aprobación del Estatuto de la Corte Permanente y su expresa mención a los principios generales consistía en la descripción del ordenamiento vigente o se estaba en presencia de una nueva fuente². Los trabajos preparatorios³ del artículo 38 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional vislumbran que, en aquellas circunstancias, se planteaba la cuestión respecto de qué debían hacer los jueces frente a las lagunas del derecho y los supuestos de ambigüedad, justamente cuando no se hallasen reglas aplicables ni en los tratados ni en la costumbre internacional. El riesgo consistía en dar la posibilidad de crear derecho a los jueces integrantes de la CPJI⁴.

El Estatuto de la actual Corte Internacional de Justicia, en su artículo 38(1)(c), menciona como fuente a los principios generales de derecho, sin establecer que provienen de las jurisdicciones internas. Ahora bien, como ya se anticipó, puntualiza que dicha fuente está integrada por aquellos principios que son reconocidos como principios jurídicos rectores en los Estados civilizados, al mencionar "reconocidos por las naciones civilizadas". Esta expresión plantea el interrogante de cuáles son las naciones consideradas civilizadas cuyos principios generales de derecho existentes en sus ordenamientos internos pueden resultar una fuente para la solución de una controversia internacional.

La doctrina ha criticado esta enunciación por considerarla una redacción con una tendencia exclusivista, toda vez que pareciera que se habla de las naciones europeas cuando se alude a la civilización. En ese sentido, se ha estimado que desde su nacimiento el derecho internacional se fue formando sobre tradiciones jurídicas occidentales, seleccionando principios de derecho privado pertenecientes a la esfera del derecho civil o del *common law*⁵.

En la obra dedicada a los principios generales de derecho, Bin Cheng analiza el contexto en el cual surgió la redacción del artículo 38 de la fenecida Corte Permanente de Justicia Internacional, cuyos términos fueron conservados en la redacción del actual Estatuto. Dicho autor postula que el reconocimiento de principios del ordenamiento interno de los Estados obedeció a la concepción que se tenía en la época de que aquellos habían sido desarrollados en la evolución de los propios sistemas jurídicos, teniendo en cuenta que muchos de ellos provienen del derecho romano.

El aludido reconocimiento de las naciones civilizadas jugaba el papel de límite a la apreciación del juez. Por otro lado, la mención de naciones civilizadas al parecer se halla vinculada con la analogía del término nación con el de gente, en lugar de Estado. El uso del vocablo "civilizadas", además de haber sido considerado como redundante, indicaría que no constituyen fuentes del derecho internacional aquellas reglas que existían en las comunidades primitivas.

2 Barberis, Julio, "Los principios generales del derecho como fuente del derecho internacional", *Revista IDH*, vol. 14 (1991), p. 19.

3 Los trabajos preparatorios constituyen un medio complementario de interpretación de los tratados internacionales, tal como lo establece el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1989.

4 Pellet, Alain, "Article 38", en *The Statute of the International Court of Justice. A Commentary*, Zimmermann, Andreas; Tomuschat, Christian y Oellers-Frahm, Karin (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 686-687.

5 En torno a esta cuestión, Carballo Leyda -relator del Grupo de Estudio de la *International Law Association* (ILA) sobre "el uso de principios de derecho privado para el desarrollo del derecho internacional" - postula que en esa construcción por intereses políticos no quedaba espacio para las reglas de Estados asiáticos o africanos, tales como China o Egipto, dando lugar a un control unilateral del desarrollo del derecho internacional. Las influencias del *common law* se reflejan en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) y las tendencias civilistas del derecho privado aparecen en el Proyecto de Responsabilidad Internacional de los Estados elaborado por la CDI en el 2001. Carballo Leyda, Alejandro, "Civilizaciones y principios del derecho internacional general", en *El discurso civilizador en derecho internacional. Cinco estudios y tres comentarios*, Gamarra Choppo, Yolanda (coord.), IFC (Institución Fernando el Católico), Zaragoza, 2011, p. 79.

En los trabajos preparatorios del Estatuto en este artículo figuran, como ejemplos los principios de *res judicata*, los principios relativos al procedimiento, la buena fe, entre otros⁶.

Más allá de esta cuestión relacionada con la sociología del derecho, la doctrina mayoritaria coincide en que los principios generales de derecho como fuente del derecho internacional público son aquellos que tienen su origen en los principales sistemas jurídicos del mundo⁷.

Resulta oportuno recordar que, con anterioridad a la creación de la Corte Permanente de Justicia Internacional, muchas diferencias internacionales sometidas a arbitraje han aplicado los principios generales como la fuente conducente a dilucidar los asuntos entre Estados. El derecho internacional en gestación del siglo XX y principios del XX llevó a considerar los principios generales como fuente de obligaciones entre los miembros de la comunidad internacional.

Así, encontramos, por ejemplo, que, en la comisión de arbitraje franco-venezolana del caso *Fabiani* (1905), se entendió que la denegación de justicia se configura tanto cuando el juez se rehúsa a ejercer sus funciones como cuando existe un retardo injustificado en dictar sentencia, y que ello surge de las reglas comunes de la mayoría de las legislaciones⁸. Este alcance de la figura de la denegación de justicia ha sido plasmado en los principios aplicables al instituto de la protección diplomática y en tratados de derechos humanos en los supuestos de imposibilidad de agotar la vía interna del Estado (requisito ineludible para acceder a la instancia internacional en ambos supuestos).

El "principio de la prescripción liberatoria" aparece presente en varios arbitrajes. A título ilustrativo podemos mencionar el caso *García Cádiz* (1885), en el cual la comisión mixta de reclamaciones italo-venezolana lo consideró como principio universalmente reconocido⁹.

La aplicación del principio de que las deudas líquidas y exigibles devengan intereses hasta su efectivo pago fue aplicado por tribunales constituidos en el marco de la Corte Permanente de Arbitraje como principio proveniente de las legislaciones internas de los Estados europeos¹⁰. Los anteriores son algunos de los ejemplos de cómo se recurría a los principios generales de derecho en los arbitrajes de la época indicada precedentemente.

La solución basada en los principios jurídicos pone de manifiesto el valor asignado a esta fuente desde el origen de la solución de controversias por el método jurisdiccional del arbitraje y su indiscutible carácter de fuente del ordenamiento internacional.

Por su parte, tanto la Corte Permanente de Justicia Internacional como su sucesora, la Corte Internacional de Justicia, han recurrido en diversas oportunidades a los principios generales de derecho.

El principio de *res judicata* fue considerado por la CPJI como aplicable al caso en el asunto de la *Sociedad Comercial de Bélgica*. Allí se discutía si las conclusiones arribadas en los laudos arbitrales eran reconocidas por las partes como autoridad de cosa juzgada. El primer laudo (03/01/1936) había ordenado la rescisión del contrato entre la Sociedad Comercial de Bélgica y Grecia, cuyo objeto era la construcción en Grecia de ciertas líneas de ferrocarril, así como el suministro del material necesario para su explotación. El contrato preveía la financiación de los trabajos con la concesión de un préstamo de la sociedad al Gobierno griego a cambio de la constitución de deuda exterior de Grecia, y establecía el arbitraje como método obligatorio de solución de controversias. Asimismo, el laudo resolvió someter a un peritaje el cálculo de la deuda. El segundo laudo (25/07/1936) fijó el monto de la deuda. Todas las disposiciones del

6 Cheng, Bin, *op. cit.*, p. 25.

7 Barberis, Julio, *op. cit.*, p. 31; Remiro Brotons, Antonio, *Derecho Internacional*, Tirant Lo Blanch, Madrid, 2007, p. 515; Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutiérrez Posse, Hortensia, *Derecho Internacional Público*, Zavalla, Buenos Aires, t. 1, 2.ª reimpr., 1987, p. 149.

8 *Caso Antoine Fabiani*, Laudo Arbitral, 31/07/1905, R.I.A.A., vol. x, p. 117 ("By reference to the general principles of the law of nations on the denial of justice, i.e., to the rules common to most legislations or taught by doctrines, one comes to decide the denial of justice comprises not only the refusal of a judicial authority to exercise its duties, and especially to render a decision on the petitions submitted to it, but also the obstinate delays on its part in rendering its sentences").

9 Moore, John B., *History and digest of International Arbitrations to which the United States has been a party*, Washington, 1898, t. 4, p. 4203, citado en Barberis, Julio, *op. cit.*, p. 15.

10 Scott, James B., *The Hague Court Reports*, Nueva York, 1916, t. 1, p. 548, citado en Barberis, Julio, *op. cit.*, p. 16.

laudo fueron ejecutadas por Grecia, a excepción de las relativas al pago de la deuda. El Gobierno helénico fundaba su actuar en que dichas deudas formaban parte de la deuda externa de Grecia y debían ser pagadas bajo esa forma, por lo cual pretendía que se le otorgara un plazo. La Sociedad y Grecia no llegaron a un acuerdo, entonces el Gobierno de Bélgica asumió la defensa de los intereses de la empresa y llevó unilateralmente el caso a la CPJI. La Corte concluyó que los laudos debían ser ejecutados en su totalidad por contar con fuerza obligatoria.

En el caso de la *Fábrica de Chorzow*, fallo emblemático en el desarrollo de la jurisprudencia internacional en materia de responsabilidad de los Estados, la CPJI aplicó el principio de que nadie puede ser juez en su propia causa (*nemo esse iudex in sua causa potest*)¹¹ y aquel que señala que infringir una obligación indica el deber de reparar¹². En dicho caso se cuestionaba la pretensión del Gobierno alemán de obtener una reparación de parte de Polonia por el perjuicio sufrido por las sociedades anónimas Oberschlesische y Bayerische, debido a la actitud tomada por el Gobierno polaco en relación con dichas empresas en el tiempo de la toma de posesión —por este último Estado— de la fábrica de nitrato situada en Chorzow, lo cual la CPJI había declarado en su fallo de 1926 como un acto contrario a las disposiciones de la Convención de Ginebra de 1922, celebrada entre Alemania y Polonia. La pretensión de Alemania consistía en obtener indemnizaciones que habían sido calculadas sobre la base de los daños que, a su juicio, habían sufrido las dos sociedades alemanas propietarias de la fábrica, y de las patentes que en ella se aplicaban; pero la Corte decidió que la reparación del perjuicio debía de revestir la forma de una indemnización global. En ese orden de ideas, postuló que la consecuencia de violar las obligaciones del acuerdo celebrado entre las partes era el deber de reparar, sin que resultara necesario que ello estuviera estipulado en forma expresa en lo convenido. Además, expuso que ninguna de las partes puso en duda que la obligación de reparar fuese un elemento del derecho internacional positivo. Finalmente, la Corte declaró la ilegitimidad de la expropiación llevada a cabo por el Estado polaco.

La CIJ, en el asunto del *Canal de Corfú*, hizo referencia a principios aplicables al procedimiento, al establecer que las presunciones de hecho o indicios o pruebas circunstanciales son admitidos en todos los sistemas jurídicos del mundo¹³, siendo estos últimos solo algunos ejemplos de los existentes. Ello debido a que la Corte puso de manifiesto que el conocimiento del minado de las aguas no podía ser imputado al Gobierno de Albania por la simple causa de que dicho campo de minas, descubiertas en aguas albanesas territoriales, había causado las explosiones por las cuales los buques de guerra británicos fueron víctimas. Pero es cierto, como lo demuestra la práctica internacional, que el Estado en cuyo territorio o aguas se ha producido un acto contrario al derecho internacional puede ser llamado a dar una explicación. No obstante, en opinión de la Corte, el Estado no puede eludir dicha solicitud alegando ignorar las circunstancias del acto y/o sus autores. En ese sentido, postula que tampoco se puede concluir del simple hecho del control ejercido por un Estado sobre su territorio y sus aguas que necesariamente sabía o debía haber sabido de cualquier acto ilícito perpetrado, ni que conocía o debió haber conocido a los autores. Este hecho en sí mismo no trae aparejada la responsabilidad del Estado ni la carga de la prueba. El control territorial ejercido por un Estado en forma exclusiva dentro de sus fronteras tiene una incidencia sobre los métodos de prueba disponibles para establecer el conocimiento de ese Estado en cuanto a ese tipo de eventos —las minas y las explosiones—. En razón de ese control exclusivo, el otro Estado, víctima de una violación del derecho internacional, no puede presentar una prueba directa de los hechos que dan lugar a la responsabilidad. Dicho Estado debe recurrir a inferencias de hecho y a pruebas circunstanciales. Esta evidencia indirecta es reconocida por las decisiones internacionales y debe ser considerada como de importancia especial cuando se basa en una serie de sucesos vinculados, y todos juntos llevan lógicamente a una sola conclusión.

Cabe recordar que en la controversia entre Argentina y Chile sobre la traza del límite entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy, el Tribunal Arbitral hizo aplicación del principio *non ultra petita partium*, destacando que resultaba competente únicamente para interpretar el laudo

11 *Fábrica de Chorzow* (Alemania c. Polonia), CPJI, Fallo, 13/09/1928, CPJI Serie A, n.º 17, p. 32.

12 *Ibid.*, p. 29.

13 *Canal de Corfú* (Reino Unido c. Albania), CIJ, Fallo, 09/04/1949, CIJ Recueil 1949, p. 18.

de 1902, en el cual se había establecido la imposibilidad material de aplicar sobre el terreno cualquiera de los criterios defendidos por las partes (la línea de la frontera siguiendo la línea de las más altas cumbres que dividan las aguas, según el mandato del Tratado de 1881). En aquel entonces, el árbitro —S.M. Británica— adoptó una línea transaccional conveniente, a su juicio, teniendo en cuenta que las partes habían aceptado esa posibilidad previamente. El Tribunal Arbitral consideró que la regla contenida en el aludido principio general se fundaba solo en una comparación entre la pretensión máxima sostenida por una parte en una controversia internacional y la pretensión de ella misma ante quien estaba llamado a interpretar la sentencia que decidió la controversia. En ese sentido, manifestó que el hecho de que el árbitro haya admitido o rechazado la pretensión máxima era irrelevante para la aplicación de esta regla. De lo anterior se desprende que consideró el laudo de 1902 como cosa juzgada¹⁴.

En la reciente interpretación de sentencia del caso del *Templo de Preah Vihear*, la CIJ puntualiza que el proceso de interpretación tiene como premisa la primacía del respeto del principio de cosa juzgada. No se debe obtener por vía de interpretación una respuesta a cuestiones que no se decidieron¹⁵.

La doctrina ha discutido si los principios a los que alude el Estatuto son aquellos provenientes de los ordenamientos internos o si bien se trata de los principios generales del derecho internacional que han surgido de la práctica constante de las naciones, como lo son la "libertad de los mares", "la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados" y "el respeto de la soberanía territorial de los Estados", entre otros.

En la citada obra de Cheng, este jurista repara en las consideraciones de la doctrina respecto a la naturaleza de dichos principios en la redacción del artículo 38¹⁶. En la actualidad, la discusión pareciera haber culminado. Los principios a los que hace referencia el artículo 38, ECIJ, son los que provienen de los ordenamientos internos.

3. Los principios generales de derecho como fuente autónoma del derecho internacional

De acuerdo con lo desarrollado en el capítulo 4, los principios generales de derecho son fuentes principales del ordenamiento jurídico internacional y comparten la jerarquía con los tratados y la costumbre internacional.

No obstante ser una fuente principal, en la práctica los principios generales de derecho cumplen una función supletoria, toda vez que se aplican en supuestos especiales vinculados a la falta de normas convencionales o consuetudinarias que vinculen a las partes de la controversia.

Los principios pueden también cumplir el rol de complementar otras normas del derecho internacional cubriendo los vacíos normativos, y ese carácter complementario se vislumbra por el contenido del principio y no necesariamente porque se verifiquen en los ordenamientos internos de los Estados¹⁷.

Sobre el particular, Remiro Brotons ha expresado:

Los tribunales internacionales pueden utilizar cualquiera de los principios generales de los ordenamientos estatales incluyendo los que inspiran sus diferentes ámbitos materiales y que son consecuencias, o concreción, de otros más genéricos y comunes a todos ellos. Esta afirmación debe ser, con todo, matizada ya que el recurso a los prin-

14 *Controversia sobre el recorrido de la traza del límite entre el hito 62 y el Monte Fitz Roy* (Argentina/Chile), Laudo Arbitral, 21/10/1994, pp. 75-76.

15 *Demanda de interpretación del fallo del 15 de junio de 1962 en el caso concerniente al Templo de Preah Vihear* (Camboya c. Tailandia), CIJ, Fallo, 11/11/2013, parág. 55.

16 Cheng, Bin, *op. cit.*, pp. 2-3.

17 Gaja, Giorgio, "General Principles of Law" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, parág. 21.

cipios sólo será pertinente en la medida en que sean compatibles con la idiosincrasia del ordenamiento jurídico internacional¹⁸.

Cuando un principio existe tanto en los derechos internos de los Estados y en el derecho internacional, es probable que su origen sea justamente en los sistemas internos, donde ha sido desarrollado en forma más amplia y aplicado con mayor frecuencia. Tal el caso, por ejemplo, del principio *pacta sunt servanda*, que constituye la piedra angular del derecho de los tratados. Sin embargo, la aplicación del principio en el derecho internacional no depende necesariamente del hecho de que este sea común a una serie de sistemas internos¹⁹. Es decir que no es condición indispensable para aplicar las reglas que puedan surgir del derecho interno de los Estados que ellas se encuentren verificadas en varios sistemas jurídicos, sino que resulte la norma apropiada para la solución del caso.

4. Los principios generales de derecho interno: origen, concepto y función

Los principios rectores a los que se recurre en los diferentes sistemas jurídicos del mundo constituyen una herramienta válida a la cual puede echar mano el juzgador para dirimir un conflicto entre Estados u otros sujetos del derecho internacional.

El origen de los principios se encuentra básicamente en el derecho romano. Los ordenamientos internos que responden al llamado derecho continental en sus códigos remiten a los principios generales de derecho en caso de lagunas o vacíos legales²⁰. Cabe recordar que el Código Napoleónico establecía que el juez, ante el silencio de la ley, acude a la razón y la equidad por haber incorporado la norma a los principios que provienen del derecho natural.

Se los podría definir como ideas, posturas éticas que pueden estar verificadas en una norma escrita o bien de tipo consuetudinaria que cumplen la función de orientar e inspirar la interpretación del ordenamiento jurídico y que son utilizados por los jueces, los legisladores y los jurisconsultos para esclarecer e interpretar normas jurídicas y aplicar en supuestos de lagunas del derecho o ante la ambigüedad de la norma²¹.

Es entonces en la definición de los principios generales que nos hallamos frente a axiomas que reflejan valores compartidos por una sociedad y que se condicionan con la ética.

La aplicación es, en la práctica, supletoria, lo que indica que solo se recurrirá a un principio general si no existe otra norma convencional o consuetudinaria, actos unilaterales o resolución de una organización internacional que brinde una solución al asunto²².

Entre ellos podemos mencionar los principios de "buena fe", *lex posterior derogat priori* (ley posterior deroga ley anterior), *lex specialis derogat general* (ley especial deroga ley general), *non bis in idem* (no dos veces por lo mismo, que refleja la prohibición de juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho), *in dubio pro reo* (en caso de duda, a favor del acusado), "todo lo que no está legalmente prohibido está permitido" (conocido como el principio de legalidad), *res iudicata* (cosa juzgada), *in claris non fit interpretatio* (ante la claridad no cabe interpretación), *venire contra factum proprium non valet* (es la máxima que expresa la doctrina de los actos propios, que indica la prohibición de actuar en contra de lo actuado), *onus probandi incumbit ei qui dicit* (el que alega un hecho debe probarlo), entre muchos otros.

En el derecho internacional existen normas convencionales que receptan principios de derecho y que se caracterizan por ser generalizados en tanto se verifican en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo. El origen del principio en el derecho interno puede provenir

18 Remiro Brotons, Antonio, *op. cit.*, p. 515.

19 Gaja, Giorgio, *op. cit.*, parág. 8.

20 Códigos civiles de Austria, Italia, Francia, España, Argentina, Colombia, Uruguay y Chile, entre otros.

21 Las llamadas *lacuna* y *non liquet* del derecho romano.

22 Sobre el particular, Barberis destaca que, cuando se quiere identificar los principios generales de derecho entre todas las normas que conforman el orden jurídico internacional, es preciso prescindir de todas aquellas que se han formado de otra manera, como lo son los tratados, la costumbre y los actos unilaterales. Barberis, Julio, *op. cit.*, p. 30.

tanto del derecho natural como de las normas escritas, sean leyes en sentido formal o en sentido material.

Así entonces, los principios constituyen una generalización de las normas del derecho interno que, según Barberis, al ser despojadas de sus elementos particulares, componen "un conjunto de principios fundamentales que aparecen como constante en un número considerable de legislaciones"²³.

La doctrina internacional es coincidente en que la aplicación de esta fuente a la solución de controversias ha sido escasa. Remiro Brotons lo atribuye a dos situaciones bien diferenciadas, la primera de ellas obedece al rechazo de los Estados considerados del tercer mundo²⁴ y las atalayas socialistas; la segunda, al temor de que en su utilización el juez internacional asuma el rol de creador del derecho²⁵.

Los principios de "buena fe" y *pacta sunt servanda* expresamente han sido incorporados a una fuente autónoma del derecho internacional, como lo es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), destacando que forman parte de los principios que la comunidad internacional reconoce como principios rectores. Así, en su preámbulo, el citado tratado establece: "Advertiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma *pacta sunt servanda* están universalmente reconocidos". En el capítulo sobre observancia de los tratados, el artículo 26 de dicho cuerpo legal determina bajo el título "Pacta sunt servanda", que "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe". Asimismo, al mencionar cómo se deben interpretar los acuerdos internacionales, el artículo 31 reza: "Regla general de interpretación. 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin".

5. Los principios generales del derecho internacional

Los denominados "principios del derecho internacional" en realidad no son una fuente autónoma del derecho internacional, sino abstracciones jurídicas de una fuente principal, sea la costumbre internacional o los tratados²⁶. La "libertad de los mares"²⁷ es un ejemplo de abstracción de la costumbre internacional, como norma que regula la actividad de los Estados en alta mar y que posteriormente ha sido receptada por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) en su artículo 87.

Otro ejemplo es la "inmunidad soberana de los Estados", que surge de la práctica común de los Estados devenida en costumbre. La Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes (2004), si bien no se encuentra en vigor, recepta las normas consuetudinarias vigentes en la materia y de manera expresa refiere a este principio general cuando establece en su preámbulo: "Considerando que las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes constituyen un principio generalmente aceptado por el derecho internacional consuetudinario". El texto del acuerdo, además de expresar el principio general, confirma que se trata de una abstracción jurídica de la costumbre.

23 *Ibid.*, p. 82.

24 Los nuevos Estados han sido reticentes en recurrir a la CIJ para solucionar sus diferencias, por considerar que ese órgano es de tendencia colonialista y occidental y por temor a quedar sometidos a reglas de cuya formación no participaron.

25 Remiro Brotons, Antonio, *op. cit.*, p. 516.

26 Moneayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutierrez Posse, Hortensia, *op. cit.*, p. 151.

27 En el caso *Lotus*, la Corte Permanente de Justicia Internacional invocó el principio de la libertad de los mares y sostuvo: "[...] en virtud del principio de libertad de los mares, un barco está en la misma situación que el territorio nacional; pero, no existe nada que sustente el argumento según el cual los derechos del Estado del pabellón puedan ir más allá de los derechos que éste ejerce dentro de su propio territorio" (traducción libre). El asunto versa sobre el ejercicio de jurisdicción penal más allá del territorio terrestre del Estado. El Estado turco hizo ejercicio efectivo de jurisdicción sobre un nacional francés por un hecho ocurrido en alta mar, consistente en el arresto del primer piloto del buque por la colisión producida entre un buque turco y uno francés y que dio lugar a la muerte de ocho ciudadanos turcos. Francia protestó por dicho procedimiento considerando violatorio del derecho internacional. *Lotus* (Francia c. Turquía), GJI, Fallo, 07/09/1927, CPJI Serie A, n.º 10, p. 25.

Ciertos principios constituyen la base del derecho internacional moderno y ellos son el de igualdad e independencia de los Estados²⁸, así como la libre determinación de los pueblos. La Carta de Naciones Unidas verifica la existencia de estos principios, tales como "la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales"; "la solución pacífica de las controversias"; la "legítima defensa"; la "igualdad soberana"; la "soberanía e independencia del Estado"; la "autodeterminación de los pueblos" y la "cooperación internacional". La Declaración 2625/XKV de 1970 ("Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas") es una expresión normativa de principios generales del derecho internacional que integran ese ordenamiento.

El proceso de formación de este tipo de normas se distingue de los principios a los que se refiere el artículo 38, inciso c, del Estatuto, tal como se hubiera resaltado antes, porque su origen proviene directamente del derecho internacional general. Sobre el particular, Jiménez de Aréchaga entiende que "surgen directamente de la naturaleza del propio Derecho Internacional por un proceso de inducción lógica [...]".²⁹

En ese sentido, cabe destacar que la CIJ considera que las palabras "principios de derecho internacional", como se emplean comúnmente, solo pueden referirse al derecho internacional en la forma en que este se aplica entre las naciones pertenecientes a la comunidad de Estados³⁰.

Estos principios o reglas generales del derecho internacional son aceptados por los Estados como normas a las que deben ajustar sus conductas; por ello han sido reconocidos como aquellas consideraciones relativas a la protección de la humanidad. Recordemos que la CIJ en el caso del *Canal de Corfú* ponderó el principio de la libertad de las comunicaciones marítimas y la obligación, para todo Estado, de no dejar utilizar su territorio para actos contrarios a los derechos de otros Estados³¹. En especial, en esa sentencia la Corte refirió que, si bien el Convenio de la Haya de 1907 es un tratado que prescribe la obligación de los Estados en tiempos de guerra, las obligaciones vinculadas a la notificación del peligro inminente que acarrearía el paso del buque por una zona minada se aplicaban aun en tiempo de paz; precisamente por tratarse de principios generales basados en las consideraciones de humanidad. Estas conclusiones fueron reiteradas casi cuarenta años después, en el caso relativo a las *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, cuando, al analizar la naturaleza consuetudinaria de los Convenios de Ginebra de 1949, alude a los principios generales del derecho humanitario como fuente vinculante³². El desarrollo progresivo del derecho internacional público ha dado lugar al surgimiento de principios que rigen en diferentes ramas de este ordenamiento jurídico. Es, entonces, que cada rama, con el avance de sus normas, ha ido desarrollando sus propios principios, tales como aquellos que integran el derecho internacional ambiental, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional.

Los principios ambientalistas en el derecho internacional giran en torno a la soberanía del Estado sobre los recursos naturales y la obligación de no causar daños al medio ambiente, lo que trae aparejada la responsabilidad en el uso de esos recursos, basándose en el principio de cooperación internacional para evitar daños a los demás Estados³³.

Por su parte, el DIH en su evolución ha diseñado los principios rectores que rigen durante la vigencia de un conflicto armado, habiendo un consenso generalizado de que constituyen

28 Estos principios han sido considerados la "espinosa dorsal" del "corpus iudicium" internacional; Jiménez de Aréchaga, Eduardo; Arbuet-Vignali, Heber y Puceiro Ripoll, Roberto, *Derecho Internacional Público. Principios, normas y estructuras*, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, t. I, 1.ª edic., 2005, p. 227.

29 *Ibid.* p. 226.

30 *Lotus*, doc. cit., p. 16.

31 *Canal de Corfú*, doc. cit., p. 122.

32 En palabras de la Corte, "la conducta de Estados Unidos puede ser juzgada de conformidad con los principios generales fundamentales de derecho humanitario"; *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. EE.UU.), CIJ, Fallo (fondo), 27/06/1986, párag. 215 (traducción libre).

33 Valverde Soto, Max, "Principios generales de derecho internacional del medio ambiente", disponible en <http://www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf>.

derivaciones de los principios de buena fe y de humanidad. En la jurisprudencia de la CIJ se encuentran reflejados varios principios generales que rigen en el derecho internacional humanitario, así encontramos que en la OC sobre la *Legalidad de las armas nucleares* se alude al principio de la "unidad y complejidad de los tratados de derecho internacional humanitario" que postula al DIH como rama del derecho internacional —el cual comprende las reglas de la guerra en lo atinente a los modos y medios de combate como aquellas que protegen a las personas durante el conflicto—. En ese sentido, expone la CIJ que "el 'derecho de La Haya' [...] estableció los derechos y las obligaciones de los beligerantes en lo que respecta a la conducción de las operaciones y limitó la elección de métodos y medios para dañar al enemigo en conflictos armados internacionales. A este desarrollo debería añadirse el 'derecho de Ginebra' (los Convenios de 1864, 1906, 1929 y 1949), que protege a las víctimas de la guerra y se propone salvaguardar a los miembros incapacitados de las fuerzas armadas y a las personas que no participan en las hostilidades"³⁴, y concluye que "dos ramas del derecho aplicable en los conflictos armados se han interrelacionado a un punto tal que se considera que paulatinamente han formado un único sistema complejo, conocido en la actualidad como derecho internacional humanitario. Las disposiciones de los Protocolos adicionales de 1977 dan expresión y prueba de la unidad y complejidad de ese derecho"³⁵.

En materia de protección de la persona humana, el pilar sobre el que se rigen las normas, sean convencionales o consuetudinarias, es el principio *pro homine*, el cual indica que estas deben interpretarse a favor del individuo. Al respecto, Mónica Pinto entiende lo siguiente:

El principio *pro homine* es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre³⁶.

Por su parte, en el ámbito del derecho de los refugiados, rige el "principio de no-devolución", el cual hace gozar de una protección especial al refugiado o solicitante de asilo o refugio hasta tanto culmine un procedimiento justo³⁷. En la Mesa Redonda de Expertos de Cambridge, organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Centro Lauterpacht de Investigaciones sobre Derecho Internacional, celebrada hace más de una década con el objeto de determinar el alcance y contenido del principio de no-devolución, se llegó a la conclusión de que este es un principio del derecho internacional consuetudinario³⁸.

Los principios expuestos en este apartado fueron enunciados meramente a título ilustrativo, sin que pueda considerarse que se ha hecho mención de todos los existentes, pero con el ánimo de mostrar que la evolución del derecho internacional es acompañada del desarrollo de nuevos principios rectores.

34 *Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares*, CIJ, Opinión Consultiva, 08/07/1996, parág. 75 (traducción libre).

35 *Ibid.*

36 Pinto, Mónica, "El principio *pro homine*. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos. La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en los tribunales locales", en *La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales*, Abregu, Martín y Courtis, Christian (coords.), CELS-Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 624.

37 La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), en su artículo 33(1) establece lo siguiente: "Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas".

38 Mesa redonda de expertos en Cambridge, 9-10/07/2001, Organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados (ACNUR) y el Centro Lauterpacht de Investigaciones sobre Derecho Internacional. El resumen de las conclusiones sobre el principio de no-devolución se encuentra disponible en <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/01151.pdf?view=1>.